

Rechtsgeschichte (Assessment) Übungen

Text 2

- I. Zusammenfassung
- II. Sachliche Aussagen
- III. Historische Verortung
- IV. Gegenwartsbezug

I. Zusammenfassung

- Auszug aus einem (deutschen) Text ohne weitere Gliederungen
- Inhaltlich
 - Frage nach
 - Funktion von Strafe,
 - insbesondere der *gerechten Strafe*
 - Strafe
 - Ist ihrem *Wesen* nach mit einem *Zweckmoment* verbunden
 - hat sich in ihrer Entstehung und historischen Entwicklung von instinktmässig-triebhafter Reaktion auf Gewalt nun objektiviert
 - Rechtsstrafe als Vervollkommnung dieser Objektivierung
 - Erforschung des Verbrechens
 - mit den Mitteln mehrerer wiss. Disziplinen
 - um einen erfolgreichen *Kampf gegen des Verbrechenertum* zu führen

II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse (1)

- Formale Strukturen des Texts ohne Ansatzpunkt
- Inhalte und Begrifflichkeiten:
 - Strafe/Strafzwecke als Themenstellungen geradezu unausweichlich
 - Verweis auf *notwendige Strafe* lässt auch ganz konkrete rechtliche Folgerungen zu
 - Begrenzung der Strafpraxis dominantes Leitmotiv im Text:
 - nur notwendige ist *gerechte Strafe*
 - Problem: die *Unverbesserlichen*
 - Sie seien weder zu köpfen noch zu hängen, sondern einzusperren
 - Deutliches Bekenntnis zu zurückhaltender Strafpraxis als zivilisatorischer *Fortschritt*

II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse (2)

- Themenbildung vor diesem Hintergrund
 - Strafzwecke in früher Neuzeit und beginnender Moderne (bis Ende des 19. Jahrhunderts)
 - Die Abschaffung der Todesstrafe
- *Alternative Themen*
 - *Strafjustiz des 19. Jahrhunderts*
 - *Die Entstehung hoheitlichen Strafens aus dem Kompositionensystem (hier etwas abwegig, aber denkbar)*
 - *Die sozialwissenschaftliche Öffnung der deutschsprachigen Rechtswissenschaft zwischen 1880 und 1930 (interessant, aber sehr anspruchsvoll)*

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Strafzwecke (1)

- Strukturierung
 - Ausprägung von Strafzwecken im historischen Längsschnitt
 - Schwerpunkt 19. Jahrhundert (arg.: Hintergrund des Textes)
 - Textdeutung vor diesem Hintergrund
- Ausgangspunkt
 - Strafzwecke und Strafgewalt setzt Existenz von (öffentlicher) Strafe voraus
 - Frühmittelalterliche Fehde und Busse als Instrumente horizontalen Unrechtsausgleichs und Sanktionen von Ehrverletzung damit nicht zu betrachten
- Zeitalter der Gottes- und Landfrieden (seit etwa ausgehendem 10. Jahrhundert)
 - Vergemeinschaftung von Unrecht durch Übernahme von Sanktionen durch Gemeinschaft oder hoheitliche Gewalt
 - Kirche
 - Landfriedensgemeinschaft
 - Zweck von Strafe
 - Vergeltung von Unrecht (Talion)
 - Abschreckung lediglich sekundärer Strafzweck

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Strafzwecke (2)

- Neubestimmung des Strafzwecks in der Neuzeit
 - CCC 1532 Art. 104: Strafe ist zu bemessen nach
 - *ergernuß der übelthatt,*
 - *auß lieb der gerechtigkeyt,*
 - *vnd vmb gemeynes nutz willen*
 - Also: Reaktion auf *Unrecht*, *Vergeltung* mit *Gemeinwohlbezug*
 - Hugo Grotius (1583-1645)
 - Strafe als *malum passionis quod infligitur ob malum actionis*
 - Strafe damit ins Verhältnis zur zum Delikt gesetzt
 - Tendenz zur Generalprävention

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Strafzwecke (3)

- Zuspitzung der Strafe auf öffentliches Interesse im Zeichen der Aufklärung
- Salus publica als Massstab der Strafe
 - *Puni delinquentes quantum ad utilitatem reipublicae opus est* (Christian Thomasius, 1655-1728, Inst., III/7101)
 - Massgeblichkeit der Todesstrafe für Wolff danach zu bemessen, *utrum tanta poena opus sit, ne furta quotidiana, nec ne* (Christian Wolff, 1679-1754, Jus Naturae, VII/3/638)

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Strafzwecke (4)

- Immanuel Kant
 - Strafe ist *absolut*
 - Vergeltung
 - Unabhängig (losgelöst) von allen anderen Zwecksetzungen
 - Hintergrund
 - Strafrecht als Bewährung des Rechts
 - Recht als Voraussetzung von Freiheit (und damit Moralität)
 - Strafe daher unabhängig von sozialen Zwecksetzungen
- Paul Johann Anselm Feuerbach (1775-1833) mit Theorie des *psychologischen Zwangs*
 - Strafe als Instrument der Unlusterzeugung beim Täter
 - Androhung von Strafe zur Steuerung des (potentiellen) Täters
 - Strafe im Interesse der *Prävention*

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Strafzwecke (5)

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831)
 - Fortsetzung kantischer Tradition: Strafe als *doppelte Negation*
 - Unrecht als Negation von Recht
 - Strafe als Negation dieser Negation
 - Herstellung des Rechts
 - Strafe also losgelöst vom Täter (und von Prävention)
 - Kritik an Feuerbachs Ansatz: Strafe wie *ein Stock, den man gegen einen Hund erhebt*
- *Klassische Schule* in Fortsetzung des hegelianischen Ansatzes, Hauptvertreter Karl Binding (1841 – 1920):
 - Strafe als Konsequenz gegen einen *Normenverstoss*
 - Strafe damit als Ausgleich von Unrecht
 - Vergeltung entscheidender Zweck von Strafe
 - Strafe ohne Bezug auf präventive Zwecksetzung oder soziale Voraussetzungen

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Strafzwecke (6)

- Begründung der modernen Schule durch *Franz von Liszt* (1851-1919)
 - Strafe weist über Vergeltung hinaus
 - Entscheidend:
 - Präventionswirkung von Strafe gegenüber Täter und anderen
 - Strafe als Instrument von
 - Besserung
 - Abschreckung
 - Schutz der Gesellschaft vor Täter
- Deutung des Texts vor diesem Hintergrund
 - Text offensichtlich mit Ausnahme des Zweckansatzes von Liszt
 - *Zweckgedanke* bestimme Mass und Ziel der Strafe
 - Gegen *blinde Reaktion*, für *zielbewussten Rechtsgüterschutz*
 - Objektivierung der Strafe in Form der *Rechtsstrafe*

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Die Abschaffung der Todesstrafe (1)

- Ausgangspunkt Textbefund (s. o.):
 - Darstellung der Strafzwecke und Problematisierung der *Unverbesserlichen*
 - Betonung, man wolle diese nicht hängen
 - Text nimmt auf Hinrichtungspraxis in offenkundig ablehnender Haltung Bezug
- Fragen damit nach
 - Praxis und Formen der Todesstrafe in der Strafrechtsgeschichte
 - Diskreditierung der Todesstrafe
 - bis hin zu ihrer Abschaffung

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Die Abschaffung der Todesstrafe (2)

- Historischer Hintergrund
 - Herrscherlich angeordnete Hinrichtungen, auch als Strafen, auf lange Tradition zurückgehend
 - Im frühen Mittelalter Teil der königlichen Gerichtsgewalt (sog. *causae maiores*)
 - Im Hochmittelalter, mit Entstehung des peinlichen Strafrechts, jedoch erst Teil eines regelrechten Sanktionenkatalogs
 - Nachdem die sog. Blutsgerichtsbarkeit auf territoriale Ebene absinkt, im Spätmittelalter auch auf unterer Ebene (Bspl. Städte) verhängt
 - Anwendung auf viele, besonders gefährliche Delikte in der Strafrechtspraxis der Vormoderne (Tötung, Raub, Diebstahl, Notzucht u dgl.)
- Form der Vollstreckung in Mittelalter und Früher Neuzeit vielfach grausam, da als Abschreckung gedacht
 - Rädern, Vierteilen, Verbrennen (blosse Enthauptung selten, da dem Adel vorbehalten)
 - Hinrichtungsrituale Teil öffentlicher Herrschaftsinszenierung

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Die Abschaffung der Todesstrafe (3)

- Beginnende Hinterfragung durch Strafrechtsdenker der Aufklärung
 - Christian Thomasius (1754): Todesstrafe nur, insoweit wirkungsvoll Delikte verhindert würden
 - Wirkungsvollste Stimme in ganz Europa insb Cesare Beccaria (*Dei delitti e delle pene*, 1764)
- Mit der frz. Revolution (1789) jedoch breiter Siegeszug der Guillotine
 - Enthauptungen nun für jeden, nicht nur den Adel vorgesehen
 - Todesqualen reduziert, zugleich effizienter, weiterhin jedoch öffentlicher Vollzug
 - Gewaltexzesse politisch motivierter Hinrichtungen
- Ab Mitte des 19. Jhs verstärken zudem aufkommende rassistische Theoreme die gesellschaftliche Akzeptanz der Todesstrafe
 - Arg.: Genetisch vorbestimmte Straftäter und Gewaltverbrecher müsse man ausschalten.
 - Fortwirken dieser Perspektive im frühen 20. Jahrhundert, in Deutschland bis hin zum nationalsozialistischen Terror

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Die Abschaffung der Todesstrafe (4)

- Aufklärerischer Ansatz setzt sich im 19. Jahrhundert fort in der sog. *modernen Schule* seit etwa 1880 (Franz v. Liszt, s.o.)
 - Da Strafe Instrument von Besserung, Todesstrafe unangebracht
- Sich ausbreitender Säkularismus lässt die Ablehnung von Todesstrafe insb. unter weltanschaulich Freigeistigen massiv steigen:
 - Starke Ablehnung im frühen sozialdemokratischen Milieu des späten 19. Jhs.
- In der deutschsprachigen Diskussion Abschaffung der Todesstrafe eng mit dem politischen Liberalismus verbunden. Dabei wechselvolle Gesetzgebung:
 - 1874 Verbot von Hinrichtungen in der BV
 - 1880er: teilweise Wiedereinführung auf Kantonsebene
 - 1942: mit Inkrafttreten des schweizerischen StGB endgültige Abschaffung der Todesstrafe in der Schweiz
 - Mehrere Initiativen zur Wiedereinführung seither gescheitert

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Die Abschaffung der Todesstrafe (5)

- International heute gemischtes Bild:
 - Seit den 1970er Jahren massiver Akzeptanzverlust der Todesstrafe in den westlichen Ländern (selbst wo sie bis anhin galt)
 - Späte Abschaffung in Spanien (nach Franco, 1978), noch später (!) in Frankreich (1981)
 - Europa derzeit ohne Todesstrafe (Ausnahme Weissrussland)
 - Anders die USA; dort jedoch langsam zunehmendes Abrücken von bisheriger Praxis; einzelne Bundesstaaten mit unterschiedlichen Rechtslagen (2021: Abschaffung der Todesstrafe in Virginia)
 - Todesstrafe unverändert praktiziert etwa in China, Indien, sowie zahlreichen afrikanische, arabischen und asiatischen Ländern

III. Historische Verortung

- Untergrenze:
 - Kritik an blinder Reaktion und Vergeltung
 - Rechtfertigung für Bindung der Strafgewalt
- Obergrenze: Rassismus
- Konkret: Franz v. Liszt,
Der Zweckgedanke im Strafrecht,
1882.

IV. Gegenwartsbezug

- Heutige Diskussionen um Wirkung moderner Strafpraxis
- Anwendung der Todesstrafe in der Gegenwart (ausserhalb Europas)
- Rechtswissenschaftliche Dogmatik und sozialwissenschaftliche Herausforderungen (Strafrecht und Kriminologie, aber auch *law and economics*)
- Gestalterische Verantwortung der Jurisprudenz für die Rechtsordnung